

1530307-23.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas; ou ainda em caso de condenação por delito de tráfico, fixação da pena em seu piso mínimo, alegando que os antecedentes do acusado são antigos e portanto, não podem ser considerados, e ainda a não aplicação do previsto no art. 42 da Lei 11.343/06 o reconhecimento da atenuante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530307-23.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530307-23.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

MAURICIO SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo apurado, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 12h35min, na Praça Júlio Prestes, nº 01, República, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de fornecimento a terceiros, 06 porções de cocaína, na forma de "crack", 02 tabletes e 04 pedras da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado e apresentou resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos dois guardas civis metropolitanos e o réu foi interrogado.

A Defesa, insistiu na diligência, anteriormente requerida pelo Ministério Público e em razão disso foi encaminhado novo ofício à Delegacia de Polícia solicitando a quebra do sigilo telemático do aparelho celular do acusado que fora apreendido no momento de sua prisão em flagrante. (fls. 152/153 e 162).

Em resposta à diligência solicitada pela Defesa a Autoridade Policial alegou impossibilidade de cumprimento do que fora requerido, já que o celular "estava inoperante", no momento em que foi recolhido e apreendido. (fls.165/166).

Assim, diante da impossibilidade da realização da perícia, foi dada por encerrada a instrução criminal e as partes foram intimadas para apresentação de seus memoriais

escritos.

Em suas alegações, o Ministério Público buscou a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. (fls. 170/176).

Já a Defesa pugnou em sede preliminar a nulidade do feito pelos seguintes motivos: "prova ilícita em razão da não realização do "aviso de Miranda" quando da prática da prisão em flagrante"; ilegalidade da busca pessoal, que teria sido feita em dissonância com o previsto no CPP; ilegalidade da abordagem que fora feita pela Guarda Civil Metropolitana que não teria atribuição legal para tal e consequente absolvição nos termos do art. 386, III do CPP. No mérito, propriamente dito, requereu ainda pela improcedência da ação penal por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Em caso de eventual condenação, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas; ou ainda em caso de condenação por delito de tráfico, fixação da pena em seu piso mínimo, alegando que os antecedentes do acusado são antigos e portanto, não podem ser considerados, e ainda a não aplicação do previsto no art. 42 da Lei 11.343/06 o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu, e ainda a aplicação da benesse prevista no §4º, do art.33 da referida lei, com fixação de regime aberto ou no máximo semiaberto para início de cumprimento de pena e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Por primeiro, não há que se falar em falta de comunicação ao réu de seu direito de ficar em silêncio.

Isso porque, não há nos autos provas dessa alegação por parte do acusado, em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido.

Ademais, verifica-se que as alegações prestadas pelos guardas civis metropolitanos no sentido de que o réu confessou que estava levando as drogas com ele apreendidas para o fluxo da "cracolândia", foram por ele também confidenciais à autoridade policial consoante o termo de interrogatório de fls. 13, após ser lhe avisado, nos seguintes termos: "Cientificado da imputação que lhe é feita, dos elementos probatórios contra si existentes, e de seus direitos e garantias constitucionais, em especial o de permanecer calado, INTERROGADO pela autoridade, às perguntas respondeu: que nesta data, um traficante lhe ofereceu R\$100,00 (cem reais) para que levasse a droga no interior do "fluxo da Cracolândia", oportunidade em que foi abordado por integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Ressalta não saber o nome do traficante, tampouco seu vulgo. . Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e assinado, fica este termo fazendo parte integrante do auto de prisão em flagrante delito".

Ora, o que seria então o "aviso de Miranda" senão os esclarecimentos prestados pela autoridade policial ao réu?

Por outro lado, apenas para que não seja alegada omissão quanto a tal direito por parte dos guardas civis, repita-se que a abordagem foi oral, cabendo a parte alegar e comprovar o fato que pretende ser utilizado para anular a prova, o que sequer foi mencionado pelo próprio réu nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Também não há que se falar busca pessoal ilícita, já que segundo os depoimentos dos autos, o réu foi abordado, por ter sido visto saindo da estação Júlio Prestes, indo em direção ao "fluxo da Cracolândia", com um volume suspeito junto a sua cintura, passando a apresentar nervosismo ao perceber que era observado pelo guardas.

Mais uma vez, o que seria a fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, e está prevista no parágrafo único, do art. 240, do CPP, senão uma pessoa que caminha rumo a "cracolândia" com um volume suspeito na cintura?

Por fim, afasta-se ainda a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante. Muito embora não tenha a Guarda Municipal poder de polícia (art. 144, §8º da Constituição Federal), nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja

encontrado em flagrante delito". Logo, qualquer agente público, incluindo os guardas civis metropolitanos estão aptos a efetuar a prisão em flagrante ao vislumbrar qualquer indivíduo cometendo crime, segundo a norma processual acima. No caso em tela, a abordagem do réu se deu durante o deslocamento do fluxo de pessoas de uma rua para outra e para tanto, realizam buscas a fim de reter objetos perfuro-cortantes para garantir a segurança de todos no local. Como já mencionado, o local dos fatos é notoriamente conhecido pelo comércio de drogas e, o réu que trazia consigo algo suspeito por baixo de sua blusa, mostrou-se nervoso no momento em que visualizou a guarda civil.

A situação assim descrita não indica qualquer desvio de função dos agentes públicos. No contexto narrado, os guardas encontraram as drogas em poder do acusado em operação comumente realizada na região da Cracolândia, sendo que da detenção, seguiu-se rigorosamente à apresentação perante autoridade policial.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma constitucional (art. 144, § 8º, da CF) limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não há nulidade na decisão impugnada, porquanto a lei processual penal, em seu art. 301 do CPP, disciplina que 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'. (...) 4. Ordem denegada." (HC 109105 / SP - Quinta turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - Julgado em 23/02/2010)

Superadas todas as preliminares levantadas pela Defesa, verifica-se que a materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e laudo de constatação dos entorpecentes, pelo laudo pericial com resultado positivo para cocaína, (fls. 10/11), fotografia de fls. 12 bem como pela prova oral colhida em solo policial e em juízo.

Com efeito, o réu nas duas oportunidades em que foi ouvido não negou ter sido preso na posse das drogas apreendidas e mais que iria levá-las para terceiros.

É fato que em juízo, modificou um pouco sua versão alegando, em suma, que não era traficante e que as drogas com ele apreendidas seriam para seu consumo e também de seus amigos que o aguardavam em uma "chácara" e que foi o encarregado pelo grupo de ir ao local para comprar a droga.

Sua versão contudo, longe de ser a confissão de que a droga era apenas para seu consumo próprio, como quis fazer crer o combativo Defensor, também não veio corroborada por outras provas, e neste sentido, bastaria que ele ao menos nominasse seus "colegas" que estavam na chácara aguardando as drogas para consumo em conjunto, para que fossem ouvidos e assim confirmasse sua versão, ou ainda esclarecesse porque estava a caminho da cracolândia e não do referido local.

Tais fatos, não foram comprovados e assim são considerados incriveis por essa magistrada ainda mais se tomarmos por base o depoimento dos guardas civis metropolitanos, Willian Costa Carvalho e Cristiano Rodrigues de Lima, que nas duas oportunidades em que foram ouvidos, diverso do ocorrido com réu, apresentaram versão idêntica sobre a dinâmica envolvendo a prisão do acusado que segundo ambos, foi visto saindo da estação de Trem, rumo ao fluxo da "cracolândia" com um volume suspeito na cintura (local onde encontraram a pedra de "crack" e ainda que se mostrou nervoso no momento em que foi visto.

Neste ponto, equivoca-se a Defesa ao mencionar que fora ouvida uma testemunha do réu, já que conforme o termo de audiência de fls. 152/153, apenas foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia (fls.79) e que são as mesmas arroladas pela Defesa a fls. 149/150.

Portanto, essas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não há que se falar em absolvição do acusado.

Cabe ainda, aqui destacar que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem guardas municipais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos

ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais e agentes públicos aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial ou guarda municipal somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos, indício que qualquer tipo de perseguição pelos guardas civis contra o acusado.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por fim, a quantidade de droga apreendida em poder do acusado, e as circunstâncias da prisão, em local notório por ser ponto de transporte de drogas para o consumo de terceiros, já são suficientes para caracterizar o crime previsto no "caput" do art. 33 a Lei de Drogas.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

"PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Neste ponto afasta-se por completo o requerimento de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art.28 do diploma legal citado.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário, no entanto consoante certidões de fls. 43/45, já foi condenado definitivamente pelos crimes de porte de arma, e lesão corporal, fatos estes que demonstram sua personalidade voltada para o crime e que sim tem o condão de aumentar a pena base, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Neste ponto, salienta-se que não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo,

por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Veja-se que a expressão "muito antigas", utilizada para requerer o afastamento das condenações por parte da combativa Defesa, é imprecisa e pode por vezes levar a situações de injustiça e até de quebra do princípio da individualização da pena, devendo o critério do julgador ser objetivo e fundado em fatos concretos, como os aqui apontados.

Assim sendo, e diante de duas condenações definitivas a pena-base deve ser aumentada em 1/5 chegando-se a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que ainda assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Ainda mais na época dos fatos em que as restrições foram abrandadas e o que se viu foi a chegada de uma nova variante a Ômicron e novo aumento de casos da doença e de centenas de morte.

Neste ponto respeitadas as posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da

conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP -Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 -Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal- Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se. Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la.

Portanto, a pena deve ainda ser aumentada em mais 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Por outro lado, não há que se falar em reconhecimento da confissão, isso porque em cada oportunidade em que foi ouvido o réu deu versão diversa para o fato de ter sido preso na posse de pedras de "crack", passando por vários delitos previstos na lei de drogas, art. 33, "caput", art. 33, §3º, art. 28; o que esvazia qualquer versão por ele apresentada.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, se mostra incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão dos maus antecedentes atestados nos autos, há provas de que o réu faz da atividade criminosa uma prática, e ainda em razão da grande quantidade de pedra de crack que era transportada pelo réu, veja-se foto de fls 12, já que não é crível que alguém desconhecido do mundo do tráfico seja aliado a transportar tamanha quantidade de drogas, notadamente pelo alto valor de comércio, em região de tão parcas condições financeiras e econômicas. Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixados no mínimo legal, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incursos nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade nos termos do artigo 44 do Código

Penal.

Por fim, considerando os maus antecedentes atestados nos autos e ainda o disposto no art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, pois se ajusta e convém ao acusado pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, já que solto, novamente foi preso pela prática de novo crime.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontram, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou. Portanto, não poderá apelar desta em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar dos acusados que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de execução definitiva e oficiem-se TRE e IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Com a juntada aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA